刑法19 筆記：犯罪利得沒收與共同沒收

來源：刑法19 課程字幕 00:50:00 ~ 01:30:00

🕮 法條原文速查

§38-1（犯罪利得沒收）
I 犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。
II 犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：
一、明知他人違法行為而取得。
二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。
三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。
III 前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
IV 第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。
V 犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。

§38-2（利得沒收計算）
I 前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之。
II 宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。

§40-2（過苛條款）
I 宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。

📋 釋字/實務見解原文速查

直接性原則（實務見解）
犯罪利得的認定須具備「直接性」，即利得須與犯罪行為之間具有**直接因果關聯**，而非間接、衍生的利益。

偷電挖礦案（實務案例）
甲竊電來挖虛擬貨幣。犯罪利得＝竊取的**電費**，而非挖到的虛擬貨幣。因為行為人犯的是**竊電**罪，所「得」的是電力，虛擬貨幣是電力的間接運用成果。

台開案（第三人利得沒收案例）
利用內線消息使第三人購買股票獲利，該第三人之獲利得宣告第三人沒收。

總額原則（最高法院見解）
犯罪利得之計算，原則上採**總額原則**，即沒收犯罪所得的全部金額，不扣除犯罪成本。但「中性成本」（即使不犯罪也會支出的成本）得予扣除。

被害人優先原則（§38-1 V）
犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。此為「被害人保護優先」之體現。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「犯罪利得沒收的前提？」	行為人實施了**實質不法行為**（不以有責性為必要）
「偷電挖礦，利得是什麼？」	利得＝**竊取的電費**（直接性原則），非虛擬貨幣
「第三人利得沒收的三要件？」	①明知違法而取得 ②無償/顯不相當對價取得 ③行為人為他人實行、他人因而取得（三擇一）
「總額原則 vs 淨利原則？」	通說採**總額原則**（不扣除犯罪成本），但**中性成本**得扣除

「販毒的毒品進貨成本可否扣除？」	**不可以**。毒品成本是犯罪直接成本，非中性成本
「被害人已取回財物，還要沒收嗎？」	**不用**。被害人優先原則（§38-1 Ⅴ）
「行為人與被害人和解賠償了，沒收怎麼算？」	已賠償部分得**扣除**，未賠償部分仍應沒收
「犯罪利得沒收是義務還是裁量？」	原則上是**義務沒收**（§38-1 Ⅰ：「沒收之」），但有過苛條款（§40-2）可裁量
「共同正犯的犯罪所得如何沒收？」	**分別沒收**（新法），不再連帶沒收；分配不明得以**估算**

一、犯罪利得沒收的審查架構

```
犯罪利得沒收審查五步驟
│
├── Step 1：有無利得？（直接性原則）
├── Step 2：利得人是誰？（行為人 vs 第三人）
├── Step 3：利得範圍多少？（總額原則/中性成本）
├── Step 4：排除事由？（被害人優先/和解扣抵）
└── Step 5：義務沒收 + 過苛條款
```

二、前提：實質不法行為

- 犯罪利得沒收的前提是行為人實施了**實質不法行為**
- **不以有責性為必要**
    - 例：14 歲的少年販毒獲利 → 雖無責任能力，仍可沒收犯罪利得
- 因為沒收的性質是「準不當得利」，重點在於**回復合法財產秩序**，不是懲罰

三、Step 1：有無利得（直接性原則）

(一) 直接性原則

犯罪利得必須與犯罪行為之間有**直接因果關聯**。

(二) 經典案例：偷電挖礦

項目	說明
事實	甲竊取電力來挖虛擬貨幣
爭點	犯罪利得是電費還是虛擬貨幣？
結論	利得＝**竊取的電費**（犯的是竊電罪，直接取得的是電力）
理由	虛擬貨幣是利用竊來的電力**間接產出**，不具直接性

> **記憶口訣**：犯什麼罪，就得什麼利。竊電 → 得電費；不是竊虛擬貨幣。

四、Step 2：利得人審查

(一) 犯罪行為人本人

- §38-1 Ⅰ：犯罪所得屬於犯罪行為人者，**沒收之**（義務沒收）

(二) 第三人利得沒收

§38-1 Ⅱ 規定三種情形（三**擇**一即可）：

款次	要件	例子
第一款	**明知**他人違法行為而取得	知道是贓物仍收受
第二款	因他人違法行為而**無償**或**顯不相當對價**取得	行為人將贓款贈與女友
第三款	犯罪行為人**為他人實行**違法行為，他人因而取得	受雇殺手的幕後雇主獲益；台開案

(三) 台開案案例

- 行為人利用內線消息，指示第三人購買股票
- 第三人獲利 → 符合第三款「行為人為他人實行，他人因而取得」
- 得對該第三人宣告沒收

五、Step 3：利得範圍

(一) 總額原則 vs 淨利原則

原則	計算方式	說明
總額原則（通說）	沒收犯罪所得**全額**，不扣犯罪成本	犯罪不應因投入成本而受保障
淨利原則	扣除成本後沒收**利潤**	已非主流見解

(二) 中性成本的例外扣除

- **中性成本**：即使不犯罪也會支出的成本
- 例如：員工薪水（不管合法經營還是犯罪經營都要付的費用）
- 中性成本得從總額中扣除

(三) 犯罪直接成本不可扣除

成本類型	可否扣除	說明
販毒的進貨成本	❌ 不可扣除	屬犯罪直接成本，非中性成本
行賄的行賄金	❌ 不可扣除	行賄金本身就是犯罪行為的一部分
員工正常薪資	☑ 得扣除	中性成本（不犯罪也要付）
租金、水電等正常營業費用	☑ 得扣除	中性成本

六、Step 4：排除審查

(一) 被害人優先原則（§38-1 V）

- 犯罪所得已**實際合法發還**被害人者 → **不予宣告沒收或追徵**
- 立法目的：避免國家沒收後，被害人反而求償無門

(二) 保險理賠的問題

- 被害人已獲保險理賠 → 保險公司取得代位求償權
- 此時犯罪所得**仍應沒收**，因為不是由行為人實際發還

(三) 和解扣抵

- 行為人與被害人和解並**已實際賠償**者 → 已賠償部分得扣除
- **尚未賠償**的部分 → 仍應沒收
- 重點：必須**實際給付**，僅有和解協議尚不足以扣抵

七、Step 5：義務沒收與過苛條款

(一) 義務沒收

- §38-1 I 規定為「沒收之」→ 為**義務沒收**
- 法官**原則上必須**宣告利得沒收

(二) 過苛條款（§40-2）

法官得**不宣告或酌減**沒收的例外事由：

1. 有**過苛之虞**
2. **欠缺刑法上之重要性**
3. 犯罪所得**價值低微**
4. 為維持受宣告人**生活條件之必要**

八、犯罪利得的共同沒收問題

(一) 舊制：連帶沒收

- 104 年修法前，共同正犯的犯罪所得採**連帶沒收**
- 問題：甲乙共同詐騙 100 萬，各沒收 100 萬＝實質沒收 200 萬，**過度沒收**

(二) 新制：分別沒收

- 104 年修法後，**各人就各人實際取得的犯罪所得分別沒收**
- 例：甲乙共同詐騙 100 萬，甲分得 60 萬、乙分得 40 萬 → 甲沒收 60 萬、乙沒收 40 萬

(三) 事實上共同處分權

- 若犯罪所得仍在**共同管領**（尚未分配），如共同帳戶中的贓款
- 此時得對有事實上共同處分權之人宣告**共同沒收**

(四) 分配不明的處理

處理方式	說明	評價
平均分別沒收	均分後各自沒收	最簡單但可能不精確
連帶沒收	回到舊制的連帶方式	有過度沒收風險
估算（§38-2 I）	法院依具體情形估算各自所得	最符合立法意旨

> §38-2 I：犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以**估算**認定之。

九、沒收競合

(一) 問題

同一筆金錢在不同犯罪角色中出現時，是否重複沒收？

(二) 行賄受賄的案例

- 甲行賄 100 萬給公務員乙
- 甲的犯罪所得＝因行賄而獲得的不法利益（如工程標案）
- 乙的犯罪所得＝收到的 100 萬賄賂
- **行賄金本身**：對甲而言是犯罪成本（不可扣除），對乙而言是犯罪所得
- 各自獨立沒收，不會重複（沒收的對象不同）

(三) 上下游交易（有上手有下手）

- 例：毒品上下游交易
- 甲（上手）賣毒品給乙（下手），乙再賣給丙
- 甲的利得＝從乙收到的毒品價金
- 乙的利得＝從丙收到的毒品價金
- **一筆錢不沒收兩次**：乙付給甲的錢，對甲是利得、對乙是成本
    - 甲的利得中已包含乙支付的金額 → 對甲沒收
    - 乙的利得只算乙從丙收到的金額 → 不重複計算